

1500729-41.2021.8.26.0575

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... a droga e não há dúvidas sobre a prática do tráfico. Dúvida há no que se refere ao crime de resistência. Na dosimetria da pena nada há que possa desabonar o réu, porém o réu vinha se dedicando ao comércio de drogas e teria sido preso por duas vezes naqueles dias exatamente por tráfico.

A defesa, por sua vez, manifestou-se pelos memoriais acostados nas pgs. 92/98, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, São José do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500729-41.2021.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500729-41.2021.8.26.0575

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2251957/2021 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 14652064 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO,
1233/21/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2251957 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AURELIO PEREIRA LEITE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida em desfavor de Aurélio Pereira Leite, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e no artigo 329, § 1º, do Código Penal, eis que no dia 19 de agosto de 2022, por volta das 19h10, na Rua Orosimbo Siqueira, nº 29, nesta cidade e comarca, Aurélio, trazia consigo 16 (dezesesseis) porções de

crack, pesando 2,25 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, Aurélio opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionários públicos competentes para executá-lo, e, em razão da resistência, o ato não se executou.

A denúncia de págs. 28/29 veio amparada no Inquérito Policial – de págs. 01/12.

O réu foi notificado (pág. 48) e apresentou defesa preliminar (págs. 55/60), alegando insuficiência de provas. Requer a absolvição sumária do acusado.

A denúncia foi recebida aos 10 de agosto de 2022 e foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (págs. 61/62).

Durante referida solenidade foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi procedido ao interrogatório do acusado, conforme termo acostado aos autos e mídia que se encontra arquivada no próprio SAJ.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi requerido.

Em sede de debates, o Ministério Público requer a procedência parcial da ação penal, absolvendo-se o réu quanto ao crime de resistência. Por outro lado, os policiais viram o réu dispensado a droga e o réu apenas negou, dizendo que era usuário. Nada desabona a palavra dos policiais cujos relatos foram harmônicos. Ambos viram o réu dispensando a droga e não há dúvidas sobre a prática do tráfico. Dúvida há no que se refere ao crime de resistência. Na dosimetria da pena nada há que possa desabonar o réu, porém o réu vinha se dedicando ao comércio de drogas e teria sido preso por duas vezes naqueles dias exatamente por tráfico.

A defesa, por sua vez, manifestou-se pelos memoriais acostados nas pgs. 92/98, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação por traficância, requerendo a desclassificação da conduta para os moldes do art. 28 da Lei de Drogas ou aplicação da causa especial de diminuição de pena. Pondera que a dúvida sempre favorece o réu, destacando a negativa de autoria. Os policiais não flagraram o réu em ato de mercancia, tampouco identificaram qualquer usuário. Ressalta a compatibilidade da quantidade de droga apreendida com posse para uso próprio e que o réu não ostenta qualquer condenação, de modo que, se condenado, merece a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Alega a atipicidade da conduta de resistência no contexto fático, uma vez que não houve lutar corporal, tendo o réu apenas se desvencilhado da abordagem. Em síntese, requer a absolvição na forma dos incisos III e VII do artigo 386 do CPP ou a desclassificação para os limites do art. 28 da Lei de Drogas. Alternativamente, pugna pela concessão do privilégio do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, observando-se a primariedade.

DECIDO.

1 -) QUESTÃO PRÉVIA

A certidão de pgs. 100 não impede o pronto julgamento do feito. O Ministério Público manifestou-se sobre a prova colhida nos debates e a defesa não se ressentiu de qualquer dificuldade para o desempenho regular de seu munus, conforme memoriais de pgs. 92/98.

Este magistrado, por sua vez, tem o hábito de prontamente transcrever de forma pessoal e direta todos os depoimentos das audiências que preside, inserindo-os no relatório da sentença previamente preparado antes das audiências.

Destarte, a transcrição do que abaixo consta, trata-se fielmente do teor da prova colhida em audiência de instrução, de modo que não há qualquer dificuldade para o julgamento em primeiro grau, inexistindo nulidade sem prejuízo.

2 -) SÍNTESE PROBATÓRIA

2.1 -) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (págs. 03/04), auto de exibição e apreensão (pág. 05), Auto de Constatação Preliminar e Laudo Pericial (pág. 10/12).

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato.

2.2 -) Das provas da autoria.

Nilton Gerlado Darroz relata que estava junto com o Cabo Francisco e avistaram o réu, sentado nas proximidades de um bar. Ele esboçou reação suspeita, entrou num bar e então o depoente viu ele arremessando algo no bar. O depoente encontrou e viu que era droga. Ele foi detido pelo cabo Francisco, mas ele conseguiu se desvencilhar, entrou em luta corporal e fugiu a pé. Quem teve contato físico com o réu foi apenas o Francisco. O réu era conhecido dos meios policiais e foi abordado por diversas vezes. A rua fica nas proximidades do "buracão", onde a traficância é muito grande. Decidiram abordar o réu porque ele é conhecido dos meios policiais e esboçou atitude suspeita e arremessou a droga atrás de um banco de concreto. Ele colocou a mão no bolso e arremessou a sacola. As testemunhas se assustaram com a presença da guarnição e se afastaram do local. Ficou apenas o réu que também não foi detido pelos motivos sustentados. O réu apenas se desvencilhou da prisão e saiu correndo a pé sentido a perimetral.

João Daniel Bento Francisco informou que estavam em patrulhamento de rotina no local conhecido por prática de tráfico e uso de drogas e viram o réu, próximo a entrada de um bar. Ele ficou muito nervoso ao visualizar a viatura e dispensou algo. O seu colega de farda foi ver o que o réu tinha jogado. Ele ficou mais nervoso ainda. Ele desvencilhou-se e evadiu-se. No pacote que ele havia jogado havia droga no pacote. Não se recorda exatamente se era pedra ou pino, mas era entre 10 a 15 porções, algo que já configurava tráfico. Tentou segurar o réu, mas ele estava molhado, suado, estava liso. Ele se desvencilhou e correu. Ele é forte e é difícil de deter. Ele era conhecido dos meios policiais por prática de uso e tráfico também. Ele era suspeito e quando ele viu a guarnição ele jogou algo para dentro do bar. Ele ficou nervoso e quando viu que o colega do depoente encontrou a porção ele ficou muito nervoso. Ele jogou o invólucro para dentro do bar. Havia outras pessoas no bar, no balcão, o dono do bar. Mas, no local que ele jogou o invólucro não tinha ninguém. Os 15 pinos estavam dentro de um invólucro plástico, provavelmente uma sacolinha. O réu não chegou a dizer nada. O réu apenas se desvencilhou

O acusado, Aurélio Pereira Leite, tem 33 anos. Trabalha de servente ou na roça. Usa

crack, quando está trabalhando. Tem uma filha de 12 anos e é separado. Foi internado duas vezes por droga. A última internação ocorreu em 2019, salvo engano. Ouviu o que os policiais disseram e não é verdade. Tinha uns moleques lá vendendo. O dono da droga saiu correndo. Não foi o depoente que dispensou as 16 porções. Tinha entrado no bar apenas para comprar uma lata de coca. Comprou a coca-cola. Sobrou troco. O dinheiro não foi apreendido. Não agrediu o policial em nenhum momento. Os mesmos policiais tinham lhe abordado em outras circunstâncias e não encontraram nada. Ali é tipo uma crackolândia e várias pessoas ficam ali para usar. Nunca desacatou a nenhum policial e não teve problemas com eles. Não tem problemas pessoais com nenhum deles. Não deu tempo de comprar a droga. Estava o depoente, uma moça e um moleque. Estavam conversando enquanto o moleque ia pegar a droga. O moleque é quem estava com o saco de droga.

3 -) DA ANÁLISE CRÍTICA E DO DIREITO APLICÁVEL

Destaque-se prontamente que a tese de desclassificação para os moldes do art. 28 da Lei de Drogas não encontra respaldo probatório, uma vez que o réu nega a posse dos entorpecentes para qualquer finalidade.

Como se extrai do interrogatório supra, o réu alegou que "o dono da droga saiu correndo", o que impede a conclusão de que o próprio réu tinha consigo as porções para uso exclusivo, uma vez que tal versão não está sustentada nem por ele próprio.

Resta ao Juízo, portanto, analisar o contexto sob a ótica dos policiais.

Nesse vértice, é preciso consignar a validade do testemunho policial, pois "goza de presunção de credibilidade".

Quanto às falas dessas testemunhas, à guisa de ter o agente atuado no feito, tenho por oportuno destacar a sua aproveitabilidade, tanto como a de qualquer pessoa. É que o depoimento do policial, em razão de sua condição de agente da Administração Pública, presume-se verdadeiro e merece crédito, mormente porque se mostra firme, coeso e em consonância com o conjunto probatório dos autos. Tal presunção, obviamente, admitiria prova em contrário, que, entretanto, não foi produzida pela defesa.

A credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar, de per si, a prova decorrente de seus testemunhos. Por mero preconceito ou suspeita infundada, não deve o Estado-Juiz entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade.

Preceitua o artigo 202 do CPP que "toda pessoa pode ser testemunha", logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob compromisso de dizer a verdade e, assim, sujeitos às penas do crime de falso testemunho. Além disso, desconsiderar a validade probatória de um depoimento levando-se em conta, apenas, a profissão de uma pessoa (por exemplo: policial militar ou civil), nada mais é do que contemplar violação ao princípio da igualdade tratando diversamente o valor de uma testemunha por sua profissão, postura essa temerária ao direito.

O escólio pretoriano bem elucida a questão:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento

testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

"A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA - STF, RTJ 68/64 E 168/199" (Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 19ª Edição, 2002, p. 176 e 182).

Ainda nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (...) Ordem denegada." (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). (grifos meus)

A perfeita identidade entre as versões, tal como se vê em solo policial e depois em Juízo, é reconhecida pela jurisprudência como fator hábil a dar validade à prova testemunhal policial.

A bem da verdade, os policiais no dia do fato, encontravam-se de serviço, realizando patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram o autor, que é conhecido nos meios policiais pelo seu envolvimento com a traficância, em pé próximo à porta de um bar, e que, o réu, ao perceber a aproximação da viatura policial, dispensou algo no chão, chamando a atenção dos policiais. Ao abordarem o réu, o mesmo resistiu a abordagem e entrou em luta corporal com os policiais, conseguindo se desvencilhar e empreender fuga a pé adentrando a mata da Av. Perimetral. No local da abordagem, no chão, foi localizado pelos policiais militares um invólucro plástico anteriormente dispensado pelo autor, e em seu interior havia 16 (dezesesseis) pedras de crack, pesando 2,25 gramas.

O réu nega ter dispensado a droga.

Todavia, nada faz crer que os policiais pudessem ter consigo 16 "pedras" de crack, pesando a 2,25 gramas, para indevidamente "forjar" cidadãos, colocando suas carreiras em risco a fim de aprisionar pessoas com as quais não mantêm qualquer desafeto ou problema pessoal.

Como o réu não alegou que a droga era para seu uso pessoal, o caso sub examen evidencia a prática de crime diverso do simples porte para uso exclusivo e pessoal de entorpecentes. Revela, na verdade, manutenção de drogas para entrega a terceiros, ficando afastada a possibilidade de desclassificação da conduta para os moldes do art. 28 da Lei 11.343/2006, tal como consignado alhures.

Sem respaldo a versão de posse para uso pessoal, tem-se que a versão dos policiais é a de que o réu de fato tinha consigo razoável quantidade de entorpecentes, superior àquela que seria necessária para o uso momentâneo e tentou dispensar as drogas com a aproximação policial.

A versão dos policiais é a única coerente.

A defesa invoca o benefício da dúvida. Contudo, não é o caso de contemplar-se o favor rei.

Conforme artigo 156 do CPP "A prova da alegação incumbe a quem a fizer [...]".

Portanto, não se trata de qualquer inversão do ônus da prova, mas sim de aplicação da dinâmica probatória imposta pelo devido processo legal.

Nesse sentido, os ensinamentos de FRAMARINO DEI MALATESTA, o qual afirma que "o princípio ontológico coloca o ônus de prova a cargo da acusação, quando considera as duas asserções contrárias, do acusador e acusado, antes da produção de provas. Mas, desde o momento em que o acusador reuniu as suas provas para sustentar a sua asserção, se o acusado, em contradição à asserção do acusador, emite simples asserção contrária, não faz mais que contrapor uma asserção não provada a uma provada e como esta tem direito de ser tomada como verdadeira de preferência a não provada, sendo a presunção da verdade, neste segundo momento, a favor do acusador, a obrigação da prova incumbe ao acusado" (A Lógica das Provas em Matéria Criminal, Campinas: Conan 1995 v. I p. 45-146 - destaque do Juízo).

O cenário probatório evidencia que o réu não dispõe de qualquer contraprova para fazer prevalecer realidade diversa daquela sustentada pelos policiais.

Encontrando-se na posse de mais de uma dezena de pedras de crack, nas proximidades de ponto de tráfico e negando que estava com as drogas para uso próprio, a única conclusão possível é a de que a conduta amolda-se a fattispecie do art. 33 da Lei de Drogas.

Cabe registrar que o réu também foi condenado nos autos da ação penal 1500674-90.2021.8.26.0575, eis que no dia 23 de agosto de 2021, por volta das 16 horas, na Avenida Maria Aparecida Salgado Bragueta, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava 34 (trinta e quatro) porções de crack, pesando 12,35 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Houve trânsito em julgado aos 22.07.2022, conforme certidão de pgs. 333 do referido processo.

Apenas para ilustrar, tem-se que no mencionado processo criminal, os policiais ouvidos naquela ocasião salientaram:

Rivaldo Luciano Tonhão, policial militar, relata que o local da abordagem é o vulgo "buracão", ponto de reconhecida traficância. Localizaram um pessoal próximo a uma pedra. O réu percebeu que ia ser abordado e tinha com ele R\$ 111,00. Localizou nas imediações mais 35 pedras de crack. Ele pulou um barranco, rompeu ligamento, caiu no rio, mas foi resgatado. Ele estava sentado no chão e debaixo dele havia uma pedra e ele escondeu a sacolinha debaixo dessa pedra. No dia 23 ele não aparentou que estivesse sob efeito de droga. Ele negou que estivesse traficando. Confirma que chegou a ver diretamente o réu escondendo a sacolinha debaixo da pedra.

João Paulo Gonçalves Parra ratifica que o local é conhecido por intenso tráfico de drogas. Optaram por abordar eles e deslocaram em direção ao grupo. Ele foi abordado diversas vezes num mesmo mês. Seria a terceira prisão dele. Ele tinha dinheiro fracionado R\$ 111,00. Quando encontraram o crack ele recebeu voz de prisão e ele pulou um barranco e se machucou, rompeu os ligamentos do joelho. O crack estava numa sacola em mãos dele. Quando as motos foram chegando ele pegou a sacola e

enfioi debaixo da pedra. Não há dúvidas de que foi ele quem escondeu a droga na pedra. No dia 11 de agosto ele foi preso e foi posto em liberdade. São 3 ocorrências, todas de crack, em menos de um mês. Ele é "nóia" também. Mas, ali é comum que as pessoas que usam também vendem, fazem uma "cota" por dia. As pessoas que estavam próximas não estavam exatamente do lado. Elas não foram abordadas. Quando iniciou a ação policial eles fugiram e havia apenas dois policiais.

Como se percebe, Aurélio não é mero usuário como tenta fazer crer. Estava em intensa traficância e tão-logo beneficiado com liberdade provisória retomava o comércio espúrio de entorpecentes.

De rigor, portanto, sua condenação nos moldes da imputação contida na denúncia.

Presente a tipicidade delitiva na forma capitulada na denúncia e não havendo justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e culpabilidade do réu, a condenação é medida necessária para a concretização dos escopos de prevenção geral positiva e prevenção especial colimados pelo sistema punitivo, além de restabelecer o princípio da prevalência do Direito e atestar a vigência da norma penal violada.

Por outro lado, o crime de resistência imputado ao réu não se configurou. Em Juízo, ambos os policiais disseram que o réu apenas se desvencilhou da abordagem e não houve prática ativa de atos de violência contra a guarnição.

O Ministério Público reconhece a improcedência desta imputação que de fato inexistiu, conforme prova colhida sob o crivo do contraditório.

4 -) DO VEREDITO, DOSIMETRIA DA PENA E DEMAIS DETERMINAÇÕES:

Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia de págs. 28/29 para CONDENAR AURÉLIO PEREIRA LEITE pela prática do crime capitulado no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, passando a dosar-lhe as penas, nos termos do artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, observa-se que o modus operandi não recomenda que seja acentuada a pena, pois a culpabilidade é normal à espécie.

O réu é primário (págs. 36/37). A condenação nos autos 1500674-90.2021.8.26.0575 refere-se a fato posterior, ocorrido aos 23.08.2021 enquanto os fatos aqui julgados passaram-se dias antes, ou seja, aos 19 de agosto de 2021.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não influenciam negativamente a dosimetria. Além disso, deixo transparecer que tais circunstâncias judiciais se analisadas em detrimento do réu evidenciam acolhimento do "direito penal de autor", fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval deste Juízo.

Na análise determinada pelo art. 42 da Lei de Drogas tem-se que o critério "quantidade" compreende duas variáveis:

1ª O peso, massa, das substâncias propriamente ditas não recomenda acréscimo, pois a apreensão foi de 2,25 gramas.

2ª A diversidade, variedade das substâncias, pois em "quantidade" de drogas podemos ter pequenas ou grandes porções de 1,2,3 ou mais drogas diferentes.

Analisando os itens o Juízo não encontra campo para acréscimo, pois não há quantidade-variedade de drogas diferentes e a quantidade de crack não pode ser considerada acima daquelas encontradas em apreensões corriqueiras nesta comarca.

O motivo do delito está albergado na própria tipicidade da traficância enquanto atividade mercantil para obtenção de lucro ilícito.

As circunstâncias do delito não recomendam o acréscimo da pena base.

Não há elementos para aferir se as consequências foram graves.

À luz dessas circunstâncias é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, em 5 anos de reclusão e 583 dias-multa.

Ausentes agravantes ou atenuantes.

Aplicável a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, posto que o réu é primário e a quantidade de entorpecentes não é suficiente para indicar ligação a organização criminosa.

Portanto, considerando que o réu era primário e não tinha contra si qualquer registro anterior por tráfico capaz de evidenciar neste caso a "dedicação a atividades criminosas", aliado ao fato de que a apreensão não possui dimensão suficiente para indicar que o réu integra organização criminosa, deve ser beneficiado com o redutor em seu patamar máximo.

Destaque-se que a dedicação a atividades criminosas foi reconhecida no processo 1500674-90.2021.8.26.0575, fato posterior, o que é coerente com a dinâmica fática em que a reiteração delitiva do réu foi interrompida.

Deste modo, reduzo a pena em 2/3 fixando-a em 01 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

À míngua de outras causas de diminuição ou aumento de pena torno em DEFINITIVA a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa.

O dia-multa tem o valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, observado o disposto no artigo 43 da Lei 11.343/2006.

Quanto ao regime prisional impõe-se prontamente reconhecer que na sessão do dia 23.06.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado "tráfico privilegiado", no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos.

O próprio Ministério Público não discordou. O parecer do subprocurador-geral da República Edson de Oliveira Almeida contém o seguinte trecho:

"A questão da hediondez do "tráfico privilegiado" está afetada ao Plenário (HC nº. 110.884/MS), aguardando julgamento. É certo que nos crimes de tráfico de drogas é necessário que o réu cumpra 2/5 da pena para obter a progressão de regime (art. 2º, § 2º, da Lei nº. 8.072/9) e 2/3 da pena para fins de livramento condicional (art. 44, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, e art. 83, V, do Código Penal). Contudo

esses prazos maiores se aplicam apenas aos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 34 a 37 da Lei 11.343/2006, sem abranger as condutas punidas pelo § 4º do art. 33, que têm menor grau de reprovabilidade e, portanto, não podem ser qualificadas pela hediondez. Donde, condenados os pacientes por tráfico privilegiado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, o resgate de 1/6 e 1/3 da pena, para a progressão de regime e livramento condicional, a teor dos artigos 112 da Lei de Execução Penal e art. 83, inciso I, do Código Penal, respectivamente."

Evidentemente que as instâncias ordinárias deverão observar se o entendimento se firmará e quais serão seus demais contornos e reflexos. Ressalvo, ainda, meu posicionamento pessoal sobre a maior adequação do regime inicial fechado para os casos de tráfico de entorpecente, que se sustentava, entretanto, também em sua equiparação a crime hediondo.

Em matéria disponível no site "Conjur", divulgada em 2016, verifica-se que novamente o E. STF entendeu pela impossibilidade de fixação do regime fechado aos casos de tráfico privilegiado. As decisões são do Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli e foram proferidas em dois pedidos de HC impetrados pelo defensor público Alexandre Orsi Netto, que atua em Sorocaba.

O Egrégio STJ revogou sua súmula 512 para acompanhar o entendimento do E. STF e tem reiteradamente concedido habeas corpus contra decisões do E. TJSP.

No Habeas Corpus nº 457.359/SP (2018/0162657-9), STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 23.08.2018 o E. STJ reafirmou a mudança de posicionamento quanto ao tema por parte da Quinta e Sexta Turmas daquela Corte Superior, que culminou na revisão do entendimento anteriormente consolidado, pela Terceira Seção, e no cancelamento do Enunciado nº 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.

A propósito: Habeas Corpus nº 391.654/SP (2017/0052379-4), STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 05.06.2017; Habeas Corpus nº 394.704/SP (2017/0074889-3), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 31.05.2017; Habeas Corpus nº 386.049/SP (2017/0013012-3), 5ª Turma do STJ, Rel. Ribeiro Dantas. DJe 19.05.2017.

A este respeito também é devida observância à súmula 440 do STJ, bem como 718 e 719 do STF, as quais também orientam a fixação do regime, ou ainda o teor da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal.

Eis o teor das súmulas citadas:

SÚMULA Nº 440 Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

SÚMULA Nº 718 A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

SÚMULA Nº 719 A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Com tais fundamentos, fixo o regime ABERTO, considerando os precedentes supra, primariedade do réu e pequena quantidade de droga apreendida.

Inviável, no entanto, a substituição da pena, a despeito da resolução nº 5/2012 do Senado Federal. Neste ponto, anoto que malgrado o assentado, v.g, no HC. 101.291 - SP, relatado pelo Ministro Eros Grau no Supremo Tribunal Federal, cerro fileiras com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no incidente de arguição de inconstitucionalidade no habeas corpus nº 120.353 - SP, cujo relator é o

Ministro Ari Pargendler, pois a individualização da pena é tarefa que incumbe primeiramente à lei e disso o legislador se desincumbiu engendrando a proibição citada no dispositivo invocado.

No mais, tenho por irretorquíveis os argumentos de Sua Excelência no sentido de que "se a lei deve assegurar indiscriminadamente ao juiz o arbítrio para, no caso do tráfico ilícito de entorpecentes, substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, o próprio artigo 44 do Código Penal seria inconstitucional ao excluir desse regime os crimes cometidos à base de violência ou grave ameaça à pessoa - e com maior razão."

Em meu entendimento, não se afigura socialmente recomendável a reinserção de traficantes ao convívio social indicando-lhes instituições públicas (escolas, asilos, centro de saúde, etc) para prestar serviços comunitários.

Ademais, considera-se que o tráfico de drogas é crime que revela grave ameaça à sociedade, portanto, com maior razão, não poderia comportar a substituição por penas restritivas de direito.

Ausente, portanto, o requisito do inciso III do art. 44 do Código Penal (suficiência da substituição).

No mesmo diapasão: Apelação nº 001224186.2010.8.26.0153, comarca de Cravinhos. Rel. Francisco Bruno, j. 16.06.2011; Apelação 990.09.063232-1, comarca de São José dos Campos. Rel. Newton Neves, j. 17.05.2011.

O descumprimento do regime aberto (adequado segundo o STF e STJ), por outro lado, pode prontamente ensejar o encarceramento por regressão ao semi-aberto e, posteriormente, até para o regime fechado.

ABSOLVO o réu pela prática do crime previsto no art. 329, § 1º do Código Penal, o que faço nos termos do inciso I do art. 386 do CPP.

Nos termos dos artigos 804 e 805 do CPP, sucumbente parcialmente, CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais que fixo em 50 UFESP's. Saliento que "A condição de beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o condenado do pagamento das custas. Eventual isenção poderá ser avaliada à época da execução da sentença condenatória, quando serão apreciadas as reais condições quanto ao estado de pobreza do réu e à possibilidade do pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Precedentes. Recurso desprovido, nos termos do voto do relator" (STJ, REsp 343.689/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, T5, DJ 22.04.03, p. 253).

Fica suspensa a cobrança na forma do § 3º do art. 98 do NCPC c.c art. 3º do CPP, pois o réu está patrocinado por advogado dativo.

Honorário na forma do convênio OAB-DPE. Expeça-se certidão, na ordem dos serviços.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

Expeça-se mandado de prisão observando o regime fixado. Faculta-se ao réu apresentar-se em Juízo no horário das 13:00 às 16:30 durante os dias úteis, ocasião em que sua audiência admonitória será "encaixada" na pauta regular, evitando-se o cumprimento de mandado de prisão em regime aberto pela Polícia a fim de prevenir eventuais intempéries que excepcionalmente podem ocorrer em situações análogas. Proceda-se ao recolhimento dos valores atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal; Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação,

com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;
Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias.
P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA